

1500120-09.2022.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Comarca: Palmital

Foro: Foro de Palmital

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... decidiu no mesmo sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Recursos defensivos - Nulidade - Ausência de autorização judicial para ingresso na residência - Denúncias anônima indicando que na residência ocorria tráfico de drogas - Fundada suspeita a justificar o ingresso dos policiais - Delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo - Tese de nulidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmital

Foro de Palmital

2ª Vara

Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital - SP - cep 19970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500120-09.2022.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500120-09.2022.8.26.0580

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luis Felipe Mendes Israel da Silva

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs a presente ação penal em face de LUÍS FELIPE MENDES ISRAEL SILVA, nascido em 04/02/2002 e já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Narrou, na inicial acusatória, que, no dia 04 de março de 2022, por volta das 21h, na Rua Pedro Elias, n.1007, nesta cidade e Comarca de Palmital-SP, o denunciado guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 02 (dois) invólucros contendo cocaína, com peso total de 347,7g, com peso líquido de 343,02g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante em 05/03/2022 (fl. 01), sendo decretada a sua prisão preventiva na mesma data (fls. 47/50).

O acusado foi notificado (fls. 93/94) e ofereceu defesa prévia (fl. 95).

A denúncia foi recebida em 26/04/2022 (fl. 96).

O réu foi citado (fl. 119).

Na fase instrutória, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 125/128).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência do pedido formulado na denúncia. Requeru ainda: a) a elevação da pena-base, em

razão do potencial vulnerante da droga; b) a não aplicação do tráfico privilegiado, pois o acusado responde por delito análogo e estava na posse de expressiva quantidade de cocaína; c) imposição de regime inicial fechado; d) seja negado o direito de recorrer em liberdade; e) a destruição do material apreendido.

A Defesa, por sua vez, sustentou, em síntese, que: a) deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea; b) deve ser reconhecida a aplicação do tráfico privilegiado; c) deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa; d) deve ser fixado regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

Não há matérias preliminares a serem apreciadas ou a presença de nulidade que deva ser conhecida de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de fl. 01, do boletim de ocorrência de fls. 02/04, dos termos de depoimentos de fls. 06/07, do auto de exibição e apreensão de fl. 08, do laudo de constatação de fls. 20/22, do exame químico-toxicológico definitivo de fls. 73/75 e das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime, por seu turno, foi comprovada por meio da prova oral produzida nos autos.

Nesse diapasão, a testemunha Luciano da Rocha Maciel, policial militar, disse que, na data dos fatos, direcionaram o policiamento para a cidade de Palmital. Afirmou que quando chegam a outra localidade é costume realizar coleta de dados para atuarem com eficácia. Informou que levantou informações sobre alguns lugares e que um deles foi onde Israel estava. Afirmou que a informação dava conta de que ele vendia drogas por quilo. Afirmou que direcionou o policiamento ao local e conseguiram identificar o local e o réu. Mencionou que, de imediato, atuaram e que, com o réu, foi feita abordagem, sendo encontrada balança de precisão com fragmentos de cocaína. Afirmou que o réu foi indagado sobre o tráfico e a venda por quilo.

Relatou que sentiu odor forte vindo da cozinha e perguntou se havia droga dentro da residência, tendo o réu dito que sim. Afirmou que, em vistoria na residência, no quarto em cima da cama encontrou porção menor de cocaína pronta para ser localizada e anotações onde constavam peso, alguns nomes, codinomes e valores. Disse que, debaixo da pia, foi encontrada quantidade maior de cocaína. Relatou que o réu disse que venderia a cocaína por seis mil reais, não declinando o nome da pessoa para quem venderia. Afirmou que deram voz de prisão ao réu por ter aquela droga ali e que ele foi conduzido ao plantão policial. Disse que não conhecia pessoalmente o réu. Acrescentou que o réu tentou se evadir para dentro da residência, porém foi abordado pelo depoente e conseguiu localizar a balança no bolso da bermuda dele. Disse que ele admitiu usar a balança para pesagem da droga e afirmou que as drogas estariam na pia e embaixo da cama. Mencionou que o peso é termo utilizado no crime. Afirmou que significa no quilo, venda de determinados gramas. Acrescentou que no peso seria a venda a quilo, a pessoa compra determinado número de gramas. Afirmou que a outra modalidade é quando vendem porções embaladas, como pedras de crack, invólucros de maconha, pinos de cocaína. Disse que o réu admitiu que as anotações eram do tráfico, não as esclarecendo. Afirmou que as anotações são vagas, pois há anotações de números, valores, codinomes, peso. Disse que a polícia possui dificuldade em identificar. Mencionou que o réu autorizou a entrada na residência. Afirmou que ao constatar a balança com fragmentos de cocaína, o odor forte e a tentativa de sair da abordagem, vislumbraram a presença de fundadas razões para entrar no local. Disse que não havia outro habitante na casa e que não encontrou nada para uso de drogas. Afirmou que não foi apreendido dinheiro e que ele faria dinheiro com essa droga. Relatou que o réu não indicou de quem teria obtido a droga. Disse que o horário foi por volta de 21 horas. Acrescentou que não se lembra da data, devido ao número de ocorrências. Afirmou que eram dois volumes de drogas, embaladas com plástico transparente. Disse que os familiares do réu moram lá.

Mencionou que as informações da venda foram coletadas para viabilizar a atuação no local. Afirmou que o réu não mencionou guardar a droga para outra pessoa, que teria adquirido para vender e fazer dinheiro, pois estava precisando. Relatou que

apresentou autorização ao réu. Informou que pede para a pessoa assinar a autorização. Mencionou que não sabe o motivo de não ter sido juntada com o flagrante. Afirmou que não dispõem de equipamento para filmagem, mas que possuem cautela para terem convicção e as fundadas razões para ingresso. Informou que não possui filmagem. Relatou que realizam levantamento com policiais locais e com pessoas que moram próximo e têm essa visão do que acontece. Disse que se dirigem ao local e olham a movimentação e o comportamento da pessoa. Informou que foram pessoas e policiais que atuam na cidade, que mencionaram que o réu venderia droga no peso, passando características. Acrescentou que foi falado que o réu vendia cocaína, entre outras drogas, mas que encontraram apenas cocaína no dia.

A testemunha Bruno Rafael Rocha dos Santos, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento de força tática e que possuíam a denúncia de que Israel traficava em Palmital. Afirmou que, com essas informações, identificaram o local e o réu e foi possível realizar a abordagem na entrada da casa, onde foi localizada balança de precisão com resquícios de cocaína e forte odor de cocaína exalando da janela da cozinha. Afirmou que o réu autorizou a entrada e acompanhou as buscas, sendo localizada quantia grande de cocaína embaixo da pia e quantia menor em cima da cama, com caderno de anotações sobre a venda de drogas. Disse que, no caderno, havia valores, quantidade e codinomes de indivíduos. Afirmou que o réu foi indagado e informou ser para venda, dizendo que havia sido mandado embora de serviço e pegou o dinheiro para adquirir a droga e revender. Acrescentou que não havia mais ninguém na residência. Afirmou que o réu admitiu usar a balança para pesar a droga. Disse que a informação veio diretamente ao comandante de equipe e que vem por policiais da região e por pessoas que não identificam com medo de represália. Afirmou que foi isso que aconteceu nesse caso. Disse que o réu foi claro, mencionando que adquiriu por um valor e que realiza a mistura com outros elementos e vende por R\$6.000,00. Afirmou que ele disse que esse seria o preço final. Disse que ele não se declarou usuário e não aparentava estar sob efeito de droga. Mencionou que o réu foi surpreendido na frente da residência e tentou adentrar correndo, porém foi abordado. Disse que os familiares do réu moram na casa ao lado e que não houve intervenção no momento da abordagem. Afirmou que começaram a sair da residência no decorrer da abordagem. Afirmou que não conhecia o réu nem de abordagens policiais, apenas levantamento de informações. Disse que a abordagem foi na Rua Pedro Elias, 1.107, mas que não recorda o bairro. Disse que foi por volta de 21h. Afirmou que a droga pesava aproximadamente 400g, 500g. Informou que não foi encontrada quantia em dinheiro, apenas as drogas, balança e o caderno. Mencionou que havia um invólucro maior e um outro menor. Disse que o réu autorizou a entrada na residência, mas já tinham fundadas razões e indícios da traficância. Mencionou que o réu disse que, com acerto que adquiriu de empresa, comprou droga e revenderia por seis mil reais. Informou que o réu assinou autorização de entrada. Mencionou que o início da abordagem começou do lado de fora da casa. Afirmou que o portão estava semiaberto. Informou que o réu tentou se evadir.

O acusado, por sua vez, na fase de inquérito, exerceu o direito ao silêncio (fl. 09).

Judicialmente, ao ser interrogado, o réu afirmou que tinha essa "situação" com o interrogando dentro de casa. Afirmou que estava guardando para outra pessoa. Relatou que estava assistindo televisão. Informou que invadiram e que disse que estava lá. Mencionou que deu graças a Deus por levarem a droga. Informou que é usuário e que agradeceu por aquilo. Disse que estava em sacola em pote de sorvete. Afirmou que estava tudo dentro do pote de sorvete. Mencionou que disse onde estava, mas que não foi pego do lado de fora. Esclareceu que essa "situação" seriam as drogas dentro da casa. Afirmou que não pode falar para quem estava guardando por segurança. Informou que fazia dois dias que a droga estava com o interrogando, que estava devendo R\$450,00. Mencionou que estava usando muita droga. Afirmou que seu terreno estava vencendo. Informou que perdeu serviço há bom tempo e começou a trabalhar de chapeiro. Afirmou que conquistou o terreno trabalhando e precisou guardar a droga, porque ele ofereceu para "matar" a dívida e lhe ajudar em R\$350,00. Afirmou que é usuário de maconha e de cocaína. Relatou que estava tudo em sacola preta, junto com pote de sorvete. Informou que não tentou correr e que

estava dentro de casa. Relatou que sua família mora ao lado. Afirmou que estava necessitando, mas que não usaria dinheiro para pagar terreno. Mencionou que seu terreno estava atrasado e que não injetaria dinheiro suado em droga. Afirmou que a droga estava em sacola preta e que estava assistindo televisão e que, quando se deparou já estavam dentro da casa. Mencionou que disse que tinha droga, mas pediu para não fazerem mal a sua família. Relatou que não conhecia os policiais. Informou que não sabe se teriam motivo para prejudica-lo, mas que a outra patrulha estava "invocada" com o interrogando, achando que estava mexendo com coisa errada. Afirmou que não sabe se seria pela pessoa que estaria guardando e que talvez por isso estavam em seu pé. Relatou que a pessoa que lhe entregou a droga sabia que o interrogando era usuário, mas que estavam abatendo em dinheiro que o interrogando devia. Afirmou que essa pessoa o ameaçou. Relatou que era usuário e que não é mais. Informou que era dependente crônico na data da prisão e que usava todos os dias. Relatou que havia sinais de uso, porque há guarda-roupa ao lado da janela, onde havia dois canudos cortados e três "tiros esticados". Disse que mostrou isso aos policiais. Afirmou que eles pediram transparência no que havia na casa, mencionando que se não fosse verdadeiro trariam o cachorro. Afirmou que liberou a entrada na casa de sua avó, onde não encontraram nada. Mencionou que estava tudo na sacola preta. Disse que não era sua letra nas anotações e que não sabe usar a balança de precisão. Relatou que nunca foi internado para tratamento, mas que já pediu para sua família. Informou que não se recorda se há documento. Afirmou que já pediu para sua mãe. Disse que não foi condenado por droga e que na ocasião disseram que era maconha. Mencionou que não sabe o motivo de como os policiais descobriram e que era algo que tinha medo. Afirmou que guardava há dois dias e que não contava para ninguém. Informou que eles estão fazendo o serviço dele e que, após eles entrarem, assumiu. Disse que não é verdade e que estava tudo junto debaixo da pia. Afirmou que estava tudo junto em sacola preta em pote de sorvete da tampa azul. Informou que assumiu que havia droga e que eles abriram o pote, tiraram da sacola e apresentaram na mesa de casa.

A despeito da versão exposta pelo réu e dos argumentos apresentados por sua nobre Defesa técnica, o quadro probatório delineado acima permite a formação de juízo de convicção acerca da autoria e da materialidade delitiva, haja vista a comprovação de que o acusado guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, substância entorpecente.

Com efeito, os policiais militares ouvidos em juízo relataram, de modo uniforme, que, após o recebimento de notícia detalhada apontando a prática do crime e indicando ser o réu o seu autor, este foi abordado em via pública de posse de instrumento usualmente utilizado para o fracionamento de substâncias entorpecentes com resquício de droga e admitiu a existência das referidas substâncias em sua residência após os policiais terem o indagado depois de sentirem odor característico de cocaína, o que foi, em seguida, confirmado pelos policiais, que se dirigiram ao local e, com a autorização do réu, encontraram a substância entorpecente mencionada na inicial acusatória, além de caderno com anotações relativas à venda de drogas.

Ressalta-se que, na situação dos autos, as palavras dos policiais apresentam confiabilidade, porquanto não foram trazidos dados verossímeis que pudessem desaboná-las e não se vislumbra que teriam qualquer motivo para prejudicar o réu. Sobre o tema, inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese"(AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

O c. Supremo Tribunal Federal também já asseverou que:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O

depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)

Destaca-se ainda que não se vislumbra irregularidade no ingresso no domicílio por parte dos policiais militares, pois o crime em apreço possui natureza permanente, prolongando, por conseguinte, a situação de flagrante e atraindo, nessa medida, a autorização prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, mormente em face das fundadas razões para ingresso decorrente da notícia de crime formulada de modo anônimo em desfavor do réu, da localização de instrumento costumeiramente empregado para o cometimento do delito em exame e da admissão do acusado aos policiais sobre a presença de drogas no local.

Em casos quejandos, o e. Tribunal de Justiça paulista decidiu no mesmo sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Recursos defensivos - Nulidade - Ausência de autorização judicial para ingresso na residência - Denúncias anônima indicando que na residência ocorria tráfico de drogas - Fundada suspeita a justificar o ingresso dos policiais - Delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo - Tese de nulidade afastada" (TJSP; Apelação Criminal 1500458-85.2018.8.26.0559; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 12/05/2021)

"Tráfico de entorpecentes - Crime permanente - Ingresso em residência - Mandado judicial - Desnecessidade - Nulidade inexistente;" (TJSP; Apelação Criminal 1500369-83.2020.8.26.0594; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/05/2021; Data de Registro: 17/05/2021)

Destarte, a quantidade e a forma de armazenamento da substância apreendida, a apreensão de instrumento costumeiramente empregado para a preparação dos entorpecentes para venda, qual seja, uma balança de precisão, além da localização de caderno com anotações relativas à venda de entorpecentes, permitem concluir, de modo cabal, que as drogas se destinavam ao comércio espúrio.

Observa-se, ademais, que não houve a caracterização de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade em favor do acusado e que este era imputável na data do delito e possuía consciência da ilicitude de sua conduta.

Frisa-se ainda a impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, haja vista que os elementos probatórios produzidos indicam a mercancia espúria, consoante detalhado alhures, inexistindo, noutra banda, substrato mínimo a indicar que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao consumo pessoal.

A prova produzida não deixa dúvidas, portanto, de que o acusado praticou a infração penal descrita na inicial acusatória, devendo responder penalmente pela conduta praticada.

Reconhece-se, noutro giro, a incidência atenuante da menoridade relativa, porquanto o acusado era menor de vinte e um anos na data do fato (CP, art. 65, I).

Constata-se também a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), pois o acusado confessou, espontaneamente, parte da infração penal que lhe fora imputada, admitindo guardar e ter em depósito as drogas em sua residência, o que foi utilizado como um dos elementos de convicção para a condenação (Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça).

Verifica-se também a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois a certidão de fl. 28 indica a primariedade do acusado e inexistem elementos indicativos de que o acusado integre organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, já que o mero cometimento de ação descrita no núcleo do tipo penal em questão não se mostra suficiente para afastar a aplicação da minorante em tela, consoante já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça em

caso quejando:

"1. Revela-se ilegal a não aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 à condenada primária e sem antecedentes criminais surpreendida na posse de pequena quantidade de entorpecentes - 4 gramas de crack e 46 gramas de maconha - quando a Corte a quo, com base na conduta criminosa que lhe foi atribuída e pela qual findou condenada, concluiu que fizesse da traficância sua profissão, sob pena de considerar toda e qualquer ação descrita no núcleo do tipo do art. 33 da Lei 11.343/06 uma situação incompatível com a aplicação da minorante em questão." (PEExt no HC 253.732/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 06/11/2013) .

Acrescenta-se, outrossim, que, embora o acusado já tenha sido condenado pela prática de ato infracional (Processo n. 1500032-49.2020.8.26.0415, conforme certidão de fl. 29), houve a aplicação unicamente da medida socioeducativa de advertência em 03/09/2020.

Dessa maneira, ausente proximidade temporal com o crime em tela, o qual fora praticado cerca de dois anos depois, além de a aplicação da medida socioeducativa mais branda entre as legalmente previstas indicar que não fora considerado grave o ato pretérito, não há como se inferir a dedicação do réu às atividades criminosas, o que justifica a incidência da minorante em apreço, conforme entendimento pacificado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos.

2. Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional (art. 1.º, § 2.º, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/2012 - SINASE).

3. No entanto, apesar de a medida socioeducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudesendo a execução penal.

4. Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável), que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena.

5. No caso concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica ao histórico infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de entorpecente.

6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação

jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.”

(EResp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021) (g.n.)

Destaca-se, ademais, que apenas a quantidade de drogas apreendidas não se mostra suficiente para afastar a aplicação da minorante em tela, conforme orientação firmada pelas Cortes Superiores.

Nesse sentido, o c. Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

“ 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.” (HC 205357 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05-11-2021 PUBLIC 08-11-2021)

“1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.” (RHC 138117 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)

“4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.” (HC 145362, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020)

Na mesma toada, o c. Superior Tribunal de Justiça:

“1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Assentou-se, ainda, a compreensão de que a utilização supletiva da natureza e quantidade da droga na terceira fase da dosimetria para afastamento da minorante somente poderá ocorrer quando esse fator for conjugado com outras circunstâncias que possam indicar a dedicação do agente à atividade criminosa ou integração à organização criminosa.

3. No caso, nenhum fato concreto, além da quantidade de droga - 2,8 toneladas de maconha -, foi utilizado para afastar a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois apenas houve presunção, com base na quantidade de entorpecente apreendido, de que o réu se dedicava a atividades criminosas e/ou integrava organização criminosa, configurando constrangimento ilegal.” (HC 659.571/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021)

“2. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

(...)

6. Hipótese em que a Corte de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes.

Contudo, o STF tem posicionamento firme de que 1A quantidade de droga apreendida

não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, public 06/04/2021).

7. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduz a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006, tornando-a definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão mais 417 dias-multa." (AgRg no HC 685.184/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

O c. Supremo Tribunal Federal tem ainda frisado a impossibilidade de emprego de processos em andamento para o afastamento da indigitada causa de diminuição. Veja-se:

"Agravamento regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4ª, da Lei 11.343/2006. Fundamentação abstrata para lastrear o afastamento do tráfico privilegiado. 5. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravamento regimental desprovido." (HC 211327 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022) (g.n.)

"2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de inquéritos ou ações penais em andamento não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Precedentes." (RHC 205080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021)

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática da conduta acima delineada, razão pela qual passo à dosimetria das penas, em atenção ao previsto no art.68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase do cálculo da sanção penal, em análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/06, observa-se que, a quantidade de drogas localizada é significativa e que a substância apreendida (cocaína) apresenta natureza especialmente lesiva, ao passo que as demais circunstâncias não lhe são desfavoráveis. Assim, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da reprimenda, presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, atenuo a pena em 1/7 (um sétimo), resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na última fase, devido à incidência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, diminuo a reprimenda em 2/3 (dois terços), de modo que a pena fica definitivamente fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Registra-se, por oportuno, que as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 já foram apreciadas na primeira fase de dosimetria, o que impossibilita o seu exame nesta fase, como forma de se evitar a consideração das mesmas circunstâncias em duplicidade, conforme tese fixada pelo c. Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 712):

"As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena." (ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014)

No mesmo sentido, pronunciou-se o c. Superior Tribunal de Justiça:

"1. Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos - 'expressiva quantidade de drogas' - na primeira etapa da dosimetria da pena, para elevar a pena-base, e na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado." (EDcl no HC 648.275/SC, Rel. Ministro OLINDO

MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (Lei n. 11.343/06, art. 43), devido à ausência de maiores apurações sobre a situação financeira do acusado.

Estabeleço o regime inicial aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a primariedade do acusado, as circunstâncias judiciais acima descritas e a quantidade de pena fixada, bem como o entendimento consolidado pelo c. Supremo Tribunal Federal (Tema 972) de que:

"1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal." (ARE 1052700 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018) Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, §2º), consistentes em (i) prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública a ser definida na fase de execução, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; e (ii) pagamento de prestação pecuniária, prevista no artigo 43, inciso I, do Código Penal, a qual fixo, considerando a condição financeira do acusado, em 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade a ser designada na fase executória. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar o réu LUÍS FELIPE MENDES ISRAEL SILVA, como incurso no art. 33, caput e §4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública a ser definida na fase de execução e pagamento de prestação pecuniária em 01 (um) salário mínimo, nos termos acima delineados, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Considerando o regime inicial acima fixado para o início do cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a manutenção da prisão preventiva do acusado consistiria em medida desproporcional, uma vez que mais gravosa do que a reprimenda fixada na sentença. Por essa razão, revogo a prisão preventiva do acusado e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se o respectivo alvará de soltura para que o acusado seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, esclareço que deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois se trata de crime de perigo abstrato, inexistindo vítima determinada.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado;
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Proceda-se, em relação à droga apreendida, conforme determinado no art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Por fim, autorizo a destruição dos demais objetos apreendidos após o trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Palmital, 02 de junho de 2022.

JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA